

1515165-28.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... abandonadas por seus proprietários, ou de crime de tráfico de pessoas durante migração forçada por desastres naturais, onde claramente se aproveita o autor dos delitos da situação de calamidade para cometer o crime".

Não é o caso dos autos.

O acusado não obteve qualquer vantagem ou facilidade na execução do crime em razão da pandemia do COVID 19, não sendo assim possível ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515165-28.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515165-28.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Réu:

JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS (R.G. 56.347.926-7 SSP/SP) foi denunciado como incurso no artigo 140, §3º, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, conforme consta da denúncia, em situação de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, no dia 11 de abril de 2021, por volta das 15h30min, na feira livre da Rua Quincas Borba, n.º 72, Sacomã, nesta cidade e comarca, injuriou CRISTINA LUCIA FERREIRA DE JESUS, ofendendo-lhe a dignidade, utilizando-se de elementos referentes à raça e cor, por meio dos dizeres "neguinha, pneu de asfalto, nega do cabelo duro".

Na data dos fatos, a vítima e o denunciado trabalhavam na feira livre existente no local dos fatos. Ao final do trabalho, a vítima aguardava alguém para ajudá-la a retirar o tabuleiro da barraca. O denunciado, irritado pois o tabuleiro estaria na passagem, passou a ofender a vítima, proferindo contra ela os seguintes dizeres: "neguinha, macaca, pneu de asfalto, nega do cabelo duro".

Os fatos foram presenciados pela testemunha Helio Lopes, que também trabalhava no local.

A vítima ofereceu representação a fls. 06.

Em 20 de outubro de 2021, a denúncia foi recebida (fls. 52/53). O réu foi citado (fls. 63). Resposta à acusação apresentada (fls. 66). Afastada a possibilidade de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de

instrução e julgamento na modalidade virtual (fls. 68/69 e 77).

Durante a fase de instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e de uma testemunha comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação do acusado, com o afastamento da majorante da pandemia e a condenação por danos morais decorrentes.

Por sua vez, a Defesa postulou a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou o afastamento da causa de aumento da pandemia, a fixação da pena no mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o direito de apelar em liberdade, afastamento da condenação por danos morais, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu pela prática do crime de injúria racial, em período de calamidade pública.

Ao final da instrução criminal, apesar dos argumentos da nobre defesa, é de rigor a PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal.

Do atento exame do acervo probatório colacionado nos autos, verifica-se que restaram suficientemente comprovadas a autoria e materialidade delitiva, especialmente através do boletim de ocorrência (fls. 03/05), termos de declarações da vítima (fls. 06 e 10), termo de depoimento da testemunha presencial (fls. 11), bem como da prova oral colhida em Juízo.

Em interrogatório policial, o réu JOSÉ CARLOS disse que é feirante há vinte e três anos. Pessoas que não o conhece o chamam pelo apelido de "Bahia", por ser baiano, e outras que o conhece o chamam pelo apelido de "Cabelo". Atualmente, trabalha como feirante, comercializando frutas em quatro feiras, entre elas a que ocorre aos sábados, na Rua Canção do Exílio, no bairro Jardim São Savério. Conhece a Sra. Cristina há uns cinco anos, pois ambos são feirantes. Contudo, não mantém qualquer relação de amizade com a Sra. Cristina. Sobre os fatos, no dia do ocorrido, deixava a feira escutando a música "Nega do Cabelo Duro" do cantor baiano Luiz Caldas. Ao passar pela vítima, Sra. Cristina, esta disse-lhe que a estava ofendendo, alegando que escutava àquela música com o intuito de se referir a cor e ao cabelo dela.

Negou tal intenção e no meio da discussão a vítima o ofendeu com os seguintes dizeres: "bandido", "fugitivo da Bahia" e "ladrão". Após ser ofendido com tais dizeres, chamou a vítima de "lixo". Nega que tenha ofendido a vítima com palavras de cunho racial, tais como: "neguinha", "pneu de asfalto", "nega do cabelo duro", "cão", "diabo", "neguinha", "macaca", bem como nega que tenha proferido ameaças como "vou pegar seus cabelos duros e arrancar na unha", "vou te dar uma voadora" e "não sei onde que eu tô que eu não te quebro toda sua nega fedorenta". Nega ter tentado agredir a Sra. Cristina. Nega ter discutido com a vítima anteriormente, ocasião em que a chamou de "nega do cabelo duro". Nunca havia tido qualquer problema com a Sra. Cristina até a data dos fatos. Quanto ao Sr. Helio, testemunha apresentada em cartório pela Sra. Cristina, alega que ele não estava no local no momento dos fatos. O Sr. Helio ajuda a Sra. Cristina a guardar o tabuleiro da barraca dela e como esse tabuleiro ainda estava no caminho quando passou ouvindo música, fato que gerou a discussão. O Sr. Hélio ainda não havia chegado para guardar o citado objeto, por isso não tem como ter ouvido o teor do entrevero.

Novamente, indagado sobre o que iniciou a discussão já que inicialmente disse que foi a música e ao término o tabuleiro, alega o declarante que foi a música pelo fato da Sra. Cristina se sentir ofendida com as palavras da canção (fls. 28/29).

Em Juízo, a ré JOSÉ CARLOS alegou que tem o apelido de "Cabelo". Trabalhava, à época, com um rapaz que vendia temperos, ou seja, as mesmas coisas que Crisstina vendia. Acabava seu trabalho antes que ela e ligava música. No caso, ela se ofendeu com uma música do Gilberto Gil que estava ouvido, ou seja, "Nega do cabelo duro". Não a ofendeu com as palavras ditas. Ela se irritava com o depoente, pois vendia seus produtos antes que ela. Não pediu para ela tirar a barraca para passar

com o caminhão. Conhece o sr. Hélio e nunca teve desentendimento com ele. A versão exculpatória apresentada pelo réu não merece credibilidade e foi contraditada pela prova produzida pela acusação, especialmente pelos seguros e convincentes depoimentos da vítima e da testemunha, inquiridas em Juízo. Assim, a vítima CRISTINA LUCIA FERREIRA DE JESUS, em Juízo, narrou que a depoente tem uma barraca na feira que fica na frente do local em que o réu entra com o caminhão. Ele chegou e disse que passaria por cima da barraca. Disse a ele que já iria desmontar a barraca. Ele disse novamente que passaria por cima e achou que fosse brincadeira, pois brincam muito na feira. Quando ele insistiu e falou que passaria por cima, respondeu que ele não faria isso e ele afirmou: Tira a barraca sua nega do cabelo duro. Num primeiro momento levou na brincadeira. No entanto, ele continuou dizendo que iria passar com o caminhão por cima. Estava desmontando a barraca e ele passou a lhe dizer que passaria por cima e desta vez a ofendeu com os seguintes dizeres: nega do cabelo duro, neguinha. Perguntou a ele se tinha certeza do que estava falando e ele falou que sim. Colocou a mão no ombro dele para que ele prestasse atenção nela e ele a chamou novamente de neguinha, pneu de asfalto, nega do cabelo duro e macaca. Várias pessoas ouviram as agressões verbais, mas na hora de ir para a delegacia, apenas o Hélio concordou em ser testemunha. O réu saiu do local e a depoente foi embora muito abalada. Gostaria, na verdade, que ele se retratasse em público, no local de seu trabalho.

A corroborar a palavra da ofendida, há o relato da testemunha arrolada pela acusação, que presenciou a discussão.

A testemunha HELIO LOPES DE FARIA, testemunha presencial, em Juízo, afirmou que no dia dos fatos estava no local e viu o ocorrido. A barraca da ré fica no meio da rua no não conseguia passar. Ela estava desmontando e ele a ofendeu com a chamando de nega fedida vou chamar a polícia. Pode chamar. Ela pediu que fosse testemunhar. Ele é agressivo e realmente falou neguinha, nega do cabelo duro, macaca

Ao final da prova oral colhida, não restam dúvidas de que JOSÉ CARLOS injuriou a vítima mediante os seguintes dizeres: "neguinha, pneu de asfalto, nega do cabelo duro", ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, utilizando-se de elementos referentes à raça e cor.

Por isso, deverá o réu responder pelo crime descrito na denúncia.

Observe que os danos causados à vítima ficaram evidenciados em seu depoimento. Ao narrar os fatos, a vítima acabou sendo obrigada a discorrer sobre o ocorrido, momento em que ficou abalada emocionalmente e chorou.

Evidente o dano causado na esfera moral da vítima.

Neste sentido, observe que o e. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a condenação do réu a indenizar os danos morais sofridos pela vítima, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (AgRg no AREsp 296025/RS; AgRg no REsp 1612912/SC e REsp 1585684/DF).

No caso dos autos, houve pedido expresso de indenização, sendo assegurado ao réu o contraditório e a ampla defesa. Noto que o pedido foi feito na denúncia pelo Parquet e diante das circunstâncias do crime e das condições econômicas das partes, fixo indenização de dois salários mínimos vigentes à época do pagamento, a título de reparação do dano moral sofrido pela vítima.

No tocante à agravante da calamidade pública, com razão a nobre defesa, pois, como já decidido por nossos Tribunais, a agravante deve ser aplicada levando em consideração a natureza do delito e as circunstâncias da ação delituosa.

Assim, embora o Estado Brasileiro tenha decretado estado de calamidade pública em data anterior aos fatos descritos na denúncia, o certo é que a natureza da calamidade em nada facilita a execução do crime em tela, bem como não aumenta a gravidade da conduta. E, ainda, a natureza do crime não agrava as consequências de tal calamidade.

Como mencionado no V. Acórdão proferido em sede de Apelação Criminal nº 1509934-05.2020.8.26.0228 -Voto nº 13766 TJSP, é "evidente que as circunstâncias previstas na alínea "j" do inciso II do artigo 61 do Código Penal devem ter relação direta com o crime praticado para que possam ser reconhecidas. É o caso, por exemplo, de crime de furto cometido após enchente, quando as casas se encontram abandonadas por seus proprietários, ou de crime de tráfico de pessoas durante migração forçada por

desastres naturais, onde claramente se aproveita o autor dos delitos da situação de calamidade para cometer o crime".
Não é o caso dos autos.

O acusado não obteve qualquer vantagem ou facilidade na execução do crime em razão da pandemia do COVID 19, não sendo assim possível reconhecer, in casu, a agravante em questão.

Desta feita, diante dos firmes relatos colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, o réu deverá responder pelos delitos previstos artigo 140, §3º, do Código Penal, bem como indenização pelo dano moral decorrente.

Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase de aplicação da pena, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, não há agravantes e eventuais atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição da pena a serem aplicadas.

Diante das condições econômicas do réu e circunstâncias dos fatos trazidas à juízo, fixo indenização por danos morais no montante de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do pagamento.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS (R.G. 56.347.926-7 SSP/SP), qualificado nos autos:

1) à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, pela prática do delito previsto no artigo 140, §3º, do Código Penal, afastando-se a incidência da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal;
2) AO PAGAMENTO de indenização dos danos morais decorrentes da ação delituosa que fixo no montante de 2 (dois) salários mínimos, vigentes à época do pagamento, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Quanto a pena corporal, presentes os requisitos legais, concedo ao réu o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ou seja, prestação de serviço à comunidade.

Assim, deverá o réu prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas com atribuição de tarefas gratuitas, na forma que for conveniente à Instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução, devendo a prestação ocorrer em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais, ressalvado que, a tarefa a ser atribuída deverá levar em conta suas aptidões, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

Em caso de revogação da substituição, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO, ante a quantidade da pena e a primariedade.

Considerando que permaneceu solto durante a instrução criminal e ainda ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Oportunamente, expeça-se a guia de recolhimento em nome do réu.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de outubro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA